EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

İKİNCİ BÖLÜM

YABANSU VE DİĞERLERİ / TÜRKİYE

(Başvuru no. 43903/09)

KARAR

STRAZBURG

12 Kasım 2012

İşbu karar AİHS'nin 44 / 2 hükmünde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir.

© T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Daire Başkanlığı tarafından yapılmış olup, Mahkeme'yi bağlamamaktadır. Bu çeviri, davanın adının tam olarak belirtilmiş olması ve yukarıdaki telif hakkı bilgisiyle beraber olması koşulu ile Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Daire Başkanlığına atıfta bulunmak suretiyle ticari olmayan amaçlarla alıntılanabilir.

Yabansu ve diğerleri / Türkiye Davasında,

Başkan

Guido Raimondi,

Yargıçlar

Danutė Jočienė,

Peer Lorenzen,

András Sajó,

Işıl Karakaş,

Nebojša Vučinić,

Helen Keller,

ve *Daire Yazı İşleri Müdürü* Stanley Naismith'in katımıyla oluşturulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (İkinci Dairesi) daire olarak, 22 Ekim 2013 tarihinde yapılan müzakerelerin ardından, aşağıdaki kararı vermiştir:

USUL

1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan (43903/09 no.lu) davanın temelinde, Türk vatandaşı olan sekiz vatandaşın (« başvuranlar ») 3 Ağustos 2009 tarihinde, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşme'nin (« Sözleşme ») 34. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvuru bulunmaktadır.

2. Başvuranlar, AİHM önünde Van'da görev yapan Avukat N. Erdal tarafından temsil edilmişlerdir. Türk Hükümeti (« Hükümet ») ise kendi görevlisi tarafından temsil edilmiştir.

3. Başvuranlar, özellikle Sözleşme'nin 2. ve 5. maddelerinin ihlal edildiğinden şikâyet etmektedirler.

4. Başvuru, 19 Ocak 2012 tarihinde Hükümet'e tebliğ edilmiştir. Sözleşme'nin 29/1 hükmü uyarınca, AİHM'in, başvurunun kabul edilebilirliği ve esası hakkında aynı anda karar vermesine hükmedilmiştir.

OLAY VE OLGULAR

I. DAVANIN KOŞULLARI

5. Başvuranlar T.C. vatandaşları olup, Muş'ta ikamet etmektedirler. Başvuranlarla ilgili bilgiler ekte yer alan tabloda sunulmuştur.

A. Davanın Ortaya Çıkışı

6. Başvuranların yakını 1986 doğumlu Selçuk Yabansu, belirtilmeyen bir tarihte, Şemdinli 3. Motorlu Piyade Taburu bünyesinde zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmeye başlamıştır.

7. Başka bir er M.F.E., 24 Şubat 2007 tarihinde aynı tabura katılmıştır. İlgili, uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu beyan etmesinin üzerine, 12 Mart 2007 tarihinde muayene edilmesi için Van Askeri Hastanesi'nin Psikiyatri Bölümü'ne sevk edilmiştir. Doktorlar, ilgilinin ankisiyete bozukluklarıyla birlikte anti sosyal davranış sergilediği teşhisinde bulunmuşlardır. İlaçla tedavi edilmesine karar vererek, düzenledikleri raporda M.F.E.'nin geri hizmete ayrılmasının ve silahsız hizmet vermesinin daha iyi olacağını belirtmişlerdir. Ayrıca, düzenli olarak muayene edilmesinin gerekli olduğu kanaatine varmışlardır.

8. Söz konusu rapor, 24 Mart 2007 tarihinde makamlara tebliğ edilmiştir.

9. Tabur Komutanı Yüzbaşı C.I., M.F.E. ile yaptığı bir görüşmenin ardından, 26 Mart 2007 tarihinde ilgiliye silah taşıtmamaya ve nöbet yükümlülüklerini vermemeye karar vermiştir. Tabur komutanı, astlarını ve M.F.E.'nin üstçavuşunu konuyla ilgili bilgilendirmiştir.

10. Yüzbaşı, 29 Mart 2007 tarihinde elli gün boyunca sürecek bir askeri operasyon için askerlerinin çoğuyla birlikte kışlayı terk etmiştir. Kışlanın ve geride kalan on dört askerin idaresini üstçavuş C.T.'ye emanet etmiştir.

11. Yüzbaşının yokluğunda C.T., M.F.E.' nin de diğer askerler gibi nöbet tutmasına, şarjörü boş olan bir silah taşımasına ancak taktik hücum yeleğinin bir cebine dolu bir şarjör yerleştirilmesine karar vermiştir. Üstçavuş C.T., soruşturma görevlilerinin ifadesini alması sırasında bu kararını yanında bulunan az sayıda asker olması ve güvenlik gerekçesiyle olduğunu ileri sürerek kararında haklılığını ileri sürmüştür.

12. M.F.E., nöbetini tamamladıktan sonra 15 Nisan 2007 tarihinde Er Selçuk Yabansu' yu nöbet değiştirme sırasında geciktiği için suçlayarak sözlü olarak ikaz etmiştir. M.F.E., Selçuk Yabansu' ya hakaret etmiş ve elinde tuttuğu kemeri fırlatmıştır. Yanlarında bulunan kişiler araya girmiştir ve tartışma orada kapanmıştır.

13. Ertesi gün, söz konusu iki asker birbirlerine çok yakın iki noktada, aynı saatlerde nöbet tutmuşlardır.

14. Saat 13.00'e doğru, M.F.E. ve Selçuk Yabansu' nun nöbet noktalarının bulunduğu bölgeden bir el ateş edilmiştir.

15. M.F.E., Selçuk Yabansu' nun vurulduğunu bağırarak kışlaya kadar koşmuştur.

16. Kendisine yapılan ilk yardım müdahalesine rağmen yaralı, olaydan kısa süre sonra hayatını kaybetmiştir.

B. Askeri Savcılık Tarafından Yürütülen Soruşturma

17. M.F.E., olayın meydana geldiği gün gözaltına alınmıştır ve ertesi gün tutuklanmıştır.

18. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma, Selçuk Yabansu' nun M.F.E. tarafından öldürüldüğünü ortaya koymuştur: aslında maktul, olay

yerinde omzunda kendi silahıyla, silahın güvenlik mandalı açık bulunmuştur ve ellerinde herhangi bir atış kalıntısı bulunmamıştır. Sonuç olarak, M.F.E.'nin ellerinden ve silahından alınan örneklerde kalıntıların bulunduğu tespit edilmiştir. Üstelik, Selçuk Yabansu, cesedinin yakınında dolu bulunan M.F.E.'nin silahıyla öldürülmüştür.

19. Van Askeri Savcılığı, 6 Temmuz 2007 tarihli iddianameyle, M.F.E. ve C.T.'nin yargılanmasına karar vermiştir. İlki kasıtlı adam öldürme, ikincisi görevlerinin icrasında ihmal suçundan yargılanmıştır. Savcılık, Yüzbaşı C.I.'ye atfedilebilir herhangi bir hata ya da ihmalin bulunmadığı, aleyhinde soruşturma yürütmenin gerekmediği kanaatine varmıştır.

20. Başvuranların itiraz etmemesiyle yüzbaşıyla ilgili soruşturmaya yer olmadığı kararı kesinleşmiştir.

C. Askeri Mahkemeler Önünde Yürütülen Ceza Yargılaması

21. Van Askeri Mahkemesi önünde 31 Ağustos 2007 tarihinde gerçekleştirilen birinci duruşmaya maktulün babası, müdahil taraf olarak katılmıştır.

22. Mahkeme, 25 Temmuz 2008 tarihli kararıyla, Üstçavuş C.T.'nin serbest bırakılmasına karar vermiştir. Mahkeme, kışlanın, kısa bir süre önce askeri üslerin maruz kaldığı birçok saldırının gerçekleştiği riskli bir bölgede konuşlanmış olduğunu ve C.T.'nin, kışlada güvenliğin sağlanması için az asker bulunması sebebiyle, M.F.E.'nin de nöbet tuttuğu koşulların kendisini zorladığını ortaya koymuştur. Mahkeme, bölgeden ayrı tutulamayan güvenlik gereksinimleri bağlamında herhangi bir ihmalin C.T.'ye atfedilemez olduğu sonucuna varmıştır.

23. Mahkeme, M.F.E.'nin durumuyla ilgili görevsiz olduğuna karar vermiştir ve davayı sivil ceza mahkemelerine sevk etmiştir.

24. Maktulün babası, 28 Temmuz 2008 tarihinde kararın C.T.'nin serbest bırakılmasına ilişkin kısmına karşı temyiz başvurusunda bulunmuştur.

25. Askeri Yargıtay Başsavcılığı, 30 Ağustos 2009 tarihli görüşlerinde, kararın bozulması gerektiği kanaatine varmıştır. Bu makama göre, kışlanın farklı nöbet noktalarına ilişkin belgelerin mahkeme tarafından istenmemiş olması sebebiyle soruşturma eksiktir. Bu eksiklik, sanığın başka bir şekilde, yani eşdeğer bir güvenlik seviyesi sağlanarak kendisine silah verilmesinden kaçınılacak şekilde nöbet görevini yerine getirip getiremeyeceği sorusuna cevap vermeye imkân vermemiştir.

26. Temyiz başvurusu, 14 Ekim 2009 tarihinde, güvenlik talimatları dikkate alınarak ve suç teşkil eden kasıtlı unsur bulunmadığı kanaatine vararak, Askeri Yargıtay tarafından reddedilmiştir.

D. M.F.E. Aleyhinde Sivil Ceza Mahkemeleri Önünde Yürütülen Dava

27. Bu süreç içerisinde Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Ocak 2009 tarihinde, M.F.E.' yi kasıtlı adam öldürmekten suçlu bulmuş ve yirmi beş yıl hapis cezasına çarptırmıştır. Ağır Ceza Mahkemesi, bu kararı verirken özellikle Adli Tıp Kurumu'nun sanığın cezai sorumluluğu bulunduğu sonucuna varan raporuna dayanmıştır.

28. Hükümetin görüşlerini sunduğu tarihte dava, Yargıtay önünde derdesttir.

E. Tazminat Talebi ve Bu Talebe İlişkin Yargılama

29. Başvuranlar, ceza yargılamalarına paralel olarak, yakınlarının ölümü nedeniyle tazminat elde etmek amacıyla Milli Savunma Bakanlığı'na başvuruda bulunmuşlardır.

30. Başvuranların talepleri iadeli taahhütlü dilekçe şeklinde 14 Nisan 2008 tarihinde Van'dan gönderilmiştir ve Ankara'da bulunan idareye 21 Nisan 2008 tarihinde tebliğ edilmiştir.

31. Başvuranlar, idare tarafından iki aydan uzun bir süre boyunca cevap verilmemesinin ardından zımnen taleplerinin reddedildiği kanısına vararak Askeri Yüksek İdare Mahkemesi önünde tam yargı davası açmışlardır.

32. Başvuranlar, psikolojik sorunları nedeniyle rahatsız olan bir erin idari görevlere verilmesini tavsiye eden bir sağlık raporu bulunmasına rağmen kendisine silah verilmesi nedeniyle idareyi suçlamaktadırlar. Başvuranlar ayrıca, olayda idarenin kusursuz bir sorumluluğun değil kusurlu bir sorumluluğun bulunduğunu ileri sürmektedirler.

33. İdare, cevap dilekçesinde, başvuranların idareye başvuru yapmak için kendilerine ayrılan bir yıllık süreye riayet etmediklerini ve dolayısıyla dava başvurularının reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.

34. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcılığı ("AYİM"), görüşlerinde, başvuranların davasının haklı olduğu sonucuna varmıştır. AYİM Başsavcılığı, kabul edilebilirlikle ilgili olarak, yapılan başvurunun idareye 21 Nisan 2008'de tebliğ edilmiş olmasına rağmen, başvuranların bu dilekçeyi 14 Nisan 2008 tarihinde yani Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne ilişkin 1602 sayılı Kanun'un 43. maddesinde öngörülen bir yıllık sürenin dolmasından önce postaladıklarını belirtmiştir.

35. AYİM Başsavcılığı, esas hakkında, idarenin görevini yerine getirmede kusurlu olduğu yönünde herhangi bir şüpheye yer olmadığı kanaatindedir. Aslında idarenin, silah taşıyamayacağı yönünde hakkında tıbbi bir rapor bulunan bir askere silah emanet ederek, başvuranların yakınına yönelik -zaten gerçekleşmiş- bir riski daha da artırdığını ve ayrıca bu kusur ile maruz kalınan zarar arasında açık bir nedensellik bağı bulunduğunu açıklamıştır.

36. AYİM Başsavcılığı, her halükarda idarenin kusursuz sorumluluğunu ileri sürmeye imkân verecek şartların da bir araya geldiğini eklemiştir.

37. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, 28 Ocak 2009 tarihinde tam yargı davası başvurusunu, idareye başvuru dilekçesinin verilmesi için ayrılan bir yıllık süreye riayet edilmediği gerekçesiyle reddetmiştir. Mahkeme, müracaatın başlangıç günü (*dies a quo*) olarak Selçuk Yabansu'nun öldüğü günü almıştır. Mahkeme, müracaat tarihinin belirlenmesiyle ilgili olarak, idareye başvuru dilekçesinin posta ile yollandığı tarihi değil idareye tebliğ edildiği tarihi dikkate almıştır. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, bu hususta sadece yerleşik ve daimi içtihatlarında değil aynı zamanda idare hukukunun genel bir ilkesinde de bahsedildiğini belirtmiştir.

38. Başvuranlar, kararın düzeltilmesi için talepte bulunmuşlardır. Başvuranlar, Yüksek Mahkeme'nin müracaat tarihi ile ilgili yaklaşımının herhangi bir yasal dayanağı olmadığını ileri sürmüşlerdir. Bu bağlamda, başvuranlar idare tarafından müracaat dilekçesinin gönderildiği değil idare tarafından alındığı tarihin dikkate alınmasını öngören hiçbir metin olmadığını ileri sürmüşlerdir. Ayrıca, başvuranlara göre, yukarıda belirtilen 1602 sayılı Kanun'un 43. madde gereğince, söz konusu süre, ancak idari işlemin ilgiliye tebliğ edildiği veya ilgilinin bu idari işlemden haberdar olduğu tarihten itibaren işlemeye başlamıştır. Bu yüzden, yine başvuranlara göre, somut olayda süre, başvuranların yargılamada müdahil taraf olduğu ve başvuranların dosya unsurlarından bilgi sahibi oldukları tarihte başlamalıydı.

39. Başvuranlar, davanın esasıyla ilgili olarak, kusursuz sorumluluğa ilişkin ilkelerden daha çok kusurlu sorumluluğu belirleyen ilkeler üzerinde durmuşlardır.

40. Başvuranlar, iddialarını güçlendirmek amacıyla, karar düzeltme taleplerine Danıştay'ın 28 Aralık 1993 tarihli bir kararının (E.1993/2163-K.1993/3856) ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin 16 Şubat 2000

(E.2000/114-K.2000/120) ile 25 Aralık 1991 (E.1990/249-K.1990/446) tarihli iki kararının nüshalarını da eklemişlerdir (aşağıdaki 47, 49 ve 50. paragraflar).

41. Başsavcılık, 7 Nisan 2009 tarihli görüşlerinde, başvurunun lehinde sonuca ulaşmıştır. Başsavcılık, 1602 sayılı Kanun'un sonunda yer alan 41. ve 43. maddeler uyarınca, Yüksek Mahkeme'yle ilgili bir çekişmeli yargı başvurusu görevsiz bir mahkemede yapıldığında veya bu mahkeme kendisinin konuyla ilgili görevsiz olduğuna dair karar aldığında başvuranın görevli Yüksek Mahkeme'ye başvurmak için otuz gün süresinin bulunduğunu ve idareye başvuruda bulunmaktan muaf olduğunu gözlemlemiştir. Başsavcılık, sonuç olarak, şayet başvuranlar müracaat dilekçelerini postaneden göndermek yerine, kendilerine yakın ve görevsiz olan herhangi bir mahkemeye sunmuşlarsa, bu başvuruların esasının Yüksek Mahkeme tarafından incelenebildiğini belirtmiştir. Dolayısıyla, Başsavcılığa göre, başvuranların müracaatını süreye riayet edilmediği gerekçesiyle reddetmek, ne haklı görülebilir ne hakkaniyete ne de 1602 sayılı Kanun'un hükümlerine uygundur. Başsavcılık diğer taraftan, başvuranların, taleplerini posta yoluyla tebliğ ederek, verilen sürenin dolmasından önce zararlarının tazminini elde etme isteklerini belirttiklerini ve söz konusu postane hizmetinin ilerleme süresinden onları sorumlu tutmanın adil olmadığını eklemiştir. Sonuç olarak, Başsavcı Yüksek Mahkeme'yi başvuruyu kabul etmeye davet etmiştir.

42. Karar düzeltme talebi, 15 Nisan 2009 tarihinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiştir.

II. İLGİLİ İÇ HUKUK VE UYGULAMALARI

A. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'yle ilgili 1602 sayılı Kanun

43. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne ilişkin 1602 sayılı Kanun'un ilgili kısımları aşağıdaki gibidir:

Görevli olmayan yerlere başvurma

Madde 41

"Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görevine giren uyuşmazlıklarda, askeri, idari ve adli yargı mercilerine açılan davaların görev noktasından reddi halinde, (…) verilen kararların tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesine dava açılabilir. Bu mercilere başvurma tarihi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesine müracaat tarihi olarak kabul edilir.

(…)"

Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması

Madde 43

" İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde dava açmadan önce, bu eylemlerin yazılı bildirimi üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde yetkili makama başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri lazımdır.

(…)

Görevli olmayan adli yargı mercilerine açılan tam yargı davasının görevden reddi halinde sonradan Askeri Yüksek İdare Mahkemesine açılan davalarda, birinci fıkrada öngörülen idareye başvurma şartı aranmaz. "

B. Taraflarca Öne Sürülen İçtihatlara İlişkin Unsurlar

44. Hükümet, askerde meydana gelen ölüm olaylarında başvurunun başlangıç gününün (*dies a quo*) belirlenmesine ilişkin Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne ait birçok kararın nüshalarını AİHM'e sunmuştur.

45. Yüksek Mahkeme, başvuranların yakınının ölümüyle ilgili 3 Aralık 2003 tarihli bir kararında (E.2003/98-K.2003/897), yine müracaatın

geç yapıldığı gerekçesiyle başvuruyu reddetmiştir. Aslında ilgililer, en geç, savcılık tarafından katillerin itham edildiği tarihten itibaren işlemeye başlayan bir yıllık süre içerisinde yetkili makamlara başvurmamışlardır ki, ilgililer ölümün meydana geldiği koşullarından bu tarihte haberdar olmuşlardır.

46. Yüksek Mahkeme, sayım sırasında başka bir asker tarafından kendisine verilen bir silahın patlamasının ardından başvuranların yakınının ölümüne ilişkin 2 Nisan 2003 tarihli başka bir kararda (E.2000/114-K.2000/120), başvuru süresinin başlangıcı olarak ölümün gerçekleştiği tarihi dikkate almıştır.

47. Yüksek Mahkeme, başka bir asker tarafından talimatlara riayet edilmediği gerekçesiyle meydana gelen ihmal sonucunda başvuranların yakınının ölümüne ilişkin 16 Şubat 2000 tarihli bir kararda (E.2000/114 - K.2000/120), başlangıç günü (*dies a quo*) olarak ilgililerin ceza davasına müdahil olarak katıldıkları günü esas almaktadır.

48. Başvuranlar, bu bahsedilen son kararın da bir nüshasını sunmuşlardır.

49. Başvuranlar, Yüksek Mahkeme'nin 25 Aralık 1991 tarihli kararını (E.1990/249-K.1990/446) tam yargı davası açtıkları sırada sunmuşlardır, bu kararın bir nüshası, Hükümet tarafından AİHM'e gönderilen yerel yargılamaya ilişkin belgeler arasında bulunmaktadır. Bu davada, askeri idare, başvuranı 27 Şubat 1986 tarihinde zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren oğlunun 17 Şubat 1986 tarihinde doğal bir ölümle hayatını kaybettiğine dair bilgilendirmiştir. İlgilinin, bir astsubay aleyhinde yürütülen ceza yargılaması çerçevesinde 19 Ocak 1990 tarihinde gerçekleştirilen bir duruşmaya tanık olarak çağırılmasından ve oğlunun başka bir askerin kendisine vurması sonucunda öldüğünü öğrenmesinden sonra bu durum meydana gelmiştir. Dolayısıyla, bir yıllık süre, ancak bu duruşmanın tarihinde işlemeye başlamalıydı, çünkü ilgili oğlunun ölümünde

idareden bir görevlinin hatası bulunduğunu bu duruşma sırasında öğrenmiştir.

50. Başvuranlar ayrıca, idareye başvurunun yapıldığı tarihin belirlenmesiyle ilgili olarak 28 Aralık 1993 tarihli bir Danıştay kararının (E.1993/2163-K.1993/3856) nüshasını da sunmuşlardır. Yüksek Mahkeme, bu kararda idare mahkemesinin bir kararına karşı idare tarafından yapılan temyiz başvurusunu, vergi cezası konusunda uzlaşma talebinin, uzlaşma komisyonuna ulaştığı tarihte değil, postaneden gönderildiği tarihte yapılmış gibi sayıldığını dikkate alarak reddetmiştir.

C. Ceza Kanunu'nun İlgili Hükümleri

51. Olayların meydana geldiği tarihte yürürlükte olan Ceza Kanunu'nun 257/2 hükmü uyarınca, "kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır".

HUKUKİ DEĞERLENDİRME

I. SÖZLEŞME'NİN 6. MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİALARI HAKKINDA

52. Başvuranlar, süreye riayet etmedikleri gerekçesiyle idari müracaatlarının reddedilmesinden şikâyet etmektedirler. Bu hususla ilgili olarak başvuranlar, bir mahkemeye erişim haklarının ihlal edildiğini ileri sürmektedirler. Başvuranlar ayrıca, tazminat taleplerini tanıması gerektiğini düşündükleri mahkemenin tarafsız olmadığını öne sürmektedirler.

Başvuranların şikâyetlerini desteklemek için ileri sürdükleri Sözleşme'nin 6. maddesi aşağıdaki gibidir:

> "Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek ve yasayla kurulmuş olan bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir. "

53. Hükümet bu iddiaya karşı çıkmaktadır.

A. Davanın başladığı günün (*dies a quo*) hesaplanması nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiası hakkında

1. Kabul Edilebilirlik Hakkında

54. AİHM, bu şikâyetin Sözleşme'nin 35/3 a) hükmü anlamında açıkça dayanaktan yoksun olmadığını ve herhangi bir kabul edilemezlik kıstasıyla bağdaşmadığını tespit ederek, kabul edilebilir olduğuna karar vermiştir.

2. Esas Hakkında

a) Tarafların İddiaları

55. Başvuranlar, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin yakınlarının ölüm tarihinden itibaren bir yıllık başvuru süresinin başvuru için tanınan sürenin bittiği gün olarak belirlemesinden şikâyet etmektedirler. Başvuranlar, ancak ceza yargılamasında müdahil tarafı oluşturduktan sonra soruşturmanın bütün unsurlarıyla ilgili bilgi sahibi olabildiklerini ve tam yargı davası başvurusu çerçevesinde idarenin tazminat talebi gerektirebilecek ağır bir kusurunun bulunduğunu tespit ettiklerini ileri sürmektedirler. Başvuranlar, bu bağlamda Yüksek Mahkeme'nin

E.2000/114–K.2000/120 ve E.1990/249-K.1991/446 sayılı kararlarına dayanmaktadırlar (yukarıdaki 47 ve 49. parag.).

56. Hükümet, erişim hakkının bir görünümünü teşkil eden "bir mahkemece yargılanma hakkının" mutlak olmadığını ve bu hakkın, kendi doğası gereği Devlet tarafından bir düzenlemeye tabi tutulması nedeniyle, özellikle bir başvurunun kabul edilebilirlik koşullarıyla ilgili olarak, zımnen kabul edilen kısıtlamalar içerdiğini AİHM'in içtihatlarından çıkarmıştır. Hükümet, bir başvurunun yapılması için gözlemlenecek süre ve işlemlere ilişkin mevzuatın, hukukun, kurallara riayetin ve özellikle adli güvenliğin, iyi idare edilmesini sağlamayı amaçladığını eklemektedir. Hükümet, somut olayda başvuranların 1602 sayılı Kanun'un 43. maddesi tarafından öngörülen süreye riayet etmedikleri görüşündedir. Hükümet, özellikle sürenin başladığı günle (*dies a quo*) ilgili olarak, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin içtihadının süreyi olay gününden itibaren başlattığını kanaatine varmıştır ki somut olayda da aynı yol izlenmiştir. Bu bağlamda Hükümet, Yüksek Mahkeme'nin birçok kararını sunmaktadır (yukarıdaki 45-47. parag.). Son olarak Hükümet, söz konusu hususta Yüksek Mahkeme'nin somut olayda sergilediği yaklaşım ile AİHM içtihatları arasında bir benzerlik bulunduğunu ileri sürmektedir.

b) AİHM'in Değerlendirmesi

57. AİHM, Sözleşme'nin 6/1 hükmünün, medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili meydana gelebilecek bütün uyuşmazlıkların bir mahkemede yargılanmasını herkes için güvence altına aldığını belirten içtihadını hatırlatmaktadır. Mahkemeye erişim hakkının bir yönünü oluşturan "mahkemece dinlenme hakkı", medeni haklardan herhangi birine müdahale edilmesini yasa dışı kılan makul sebepleri bulunan ve buna benzer şikâyetlere ilişkin iddiaları, Sözleşme'nin 6/1 maddesinin gerekliklerine cevap veren bir mahkeme tarafından yargılanma imkânına sahip

olamamaktan şikâyet eden herkes tarafından ileri sürülebilmektedir. (*Golder / Birleşik Krallık*, 21 Şubat 1975, § 36, Seri A, no. 18).

58. AİHM ayrıca, bir mahkemeye erişim hakkının, mutlak bir hak olmadığını ve özellikle başvurunun kabul edilebilirlik koşullarıyla ilgili olarak bazı dolaylı kısıtlamalara tabi tutulabileceğini, zira bu bağlamda kendi niteliği dolayısıyla, kesin bir takdir yetkisinden istifade eden, Devlet tarafından düzenlenmiş bir mevzuat gerektirdiğini hatırlatmaktadır. Bununla birlikte, bu sınırlamalar, yargılanma hakkı kendi özünde ihlal edilerek, yargılanabilir kişiye açık olan erişimi engelleyemez. Ayrıca uygulanan kısıtlamalar, şayet meşru bir amaç güdüyorlarsa ve hedeflenen amaç ile kullanılan yöntemler arasında makul bir orantılılık ilgisi bulunuyorsa, Sözleşme'nin 6/1 hükmüyle uyumlu olmaktadır (*S.A. Sotiris ve Nikos Koutras Attee / Yunanistan*, no. 39442/98, § 15, AİHM 2000-XII).

59. AİHM son olarak, dava açma ya da başvuru hakkının, ilgililerin etkin olarak, kendilerine bir yükümlülüğü zorunlu kılan veya meşru çıkarlarına ya da haklarına ihlal teşkil edebilen adli kararlardan haberdar olabildikleri andan itibaren icra edilmesi gerektiğini hatırlatmaktadır (*Miragall Escolano ve diğerleri / İspanya*, no. 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 ve 41509/98, § 37, AİHM 2000-I ve *Cañete de Goñi / İspanya*, no. 55782/00, § 40, AİHM 2002 VIII).

60. AİHM, somut olayda başvuranlar tarafından, zaman aşımı sürelerinin çok kısa olduğunun veya bu sürelerin kendi içerisinde başvuranların bir mahkemeye erişim haklarına ihlal teşkil ettiğinin iddia edilmediğini, başvuranların, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne ilişkin Kanun'un 43. maddesince, idareye başvurularını sunmaları için verilen bir yıllık süreye itiraz etmediklerini dikkate almaktadır.

61. Aslında, bir yıllık süre sona erdiğinde davanın zaman aşımına uğramış sayıldığı ve bu sürenin başlangıç tarihinin (*dies a quo*) belirlenmesi hususu davanın merkezinde bulunmaktadır.

62. AİHM, 1602 sayılı Kanun'un 43. maddesinin, idari müracaatta bulunmak için belirlenen bir yıllık sürenin, tazminata yol açan veya başvuranların başka bir yolla bilgi sahibi oldukları idari eylemin tebliğ edildiği tarihte işlemeye başladığına hükmettiğini gözlemlemektedir.

63. AİHM, başvuranların tam yargı davası açarak, olayda idarenin kusurlu sorumluluğu bulunduğunu göstermeye çalıştıklarını tespit etmektedir. Kusurlu sorumluluk, üç unsurun bir araya geldiğini varsaymaktadır: idarenin kusuru, tazminat ve maruz kalınan zarar ile kusur arasındaki nedensellik bağı.

64. AİHM, idarenin kusurunu, kusurlu sorumlulukta davanın temelini ve yakınlarının ölümüyle davada tazminat yolunu teşkil eden bir unsurun da silah taşımasına izin verilmemiş bir ere silah verilmesi olduğunu dikkate almaktadır.

65. Dosyada yer alan hiçbir unsur, makamların, cinayet hakkında tıbbi bir raporun ve askeri üstlerin M.F.E.'ye silah verilmesini yasaklayan bir talimatlarının bulunduğuna ilişkin başvurana bilgi verdiklerini belirtmeye imkân vermemektedir (*Díaz Ochoa / İspanya*, no. 423/03, § 47, 22 Haziran 2006 ve *Lacárcel Menéndez / İspanya*, no. 41745/02, § 33, 15 Haziran 2006).

66. Dolayısıyla, böyle bir tebliğ bulunmadığından, 1602 sayılı Kanun'un 43. maddesine göre, başka bir yöntemle haberdar oldukları tarihte, süre işlemeye başlamak zorunda kalmıştır.

67. Hâlbuki başvuranların, olayın meydana geldiği tarihte bu unsurun varlığını bilmediklerini ve olayla ilgili bilgi sahibi olamadıkları gibi ceza dosyasına erişim sağladıktan, başka bir deyişle soruşturmanın kapanmasından ve iddianamenin oluşturulmasından sonra tazminat haklarının gereğini yapamadıklarını kabul etmek gereklidir. Dolayısıyla başvuranlar, özellikle soruşturmanın kapanmasından sonra soruşturmanın unsurlarına erişim sağlamışlar, idarenin kusurlu olması olasılığından

haberdar olmuşlar ve idareye karşı hukuki olarak dava açma imkânına sahip olmuşlardır.

68. Bu bağlamda AİHM, bir başvurunun süresinin yalnızca, başvuranın geçerli şekilde hareket edebileceğini ileri sürdüğü günden yani haklarını ihlal eden karardan veya işlemden haberdar olduğu ya da olabildiği ve bu duruma karşı hareket etmek istediği andan itibaren işlemeye başlayabileceğini tekrar belirtmektedir (daha önce anılan *Miragall Escolano ve Cañete de Goñi*).

69. Diğer taraftan AİHM, taraflarca sunulan kararlar bakımından (yukarıdaki 44 – 49. parag.), Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından kabul edilen yaklaşımın, olayların meydana geldiği tarihte yerleşik ve daimi olmadığını dikkate almaktadır. Aslında mahkemenin kararlarından bazıları, zarara uğranılan tarihi sürenin başlangıç tarihi olarak kabul ederken, diğer kararlar, ceza yargılamasında mağdur tarafın davaya dâhil olduğu sırada maruz kalınan zararın kaynağında idarenin kusurlu olduğundan haberdar olduğu tarihi, sürenin başlangıcı olarak kabul etmektedirler.

70. Başvuranların, iddianamenin oluşturulmasından sonra bir yıldan daha az bir zaman içerisinde idareye başvurularını sundukları ve her ne olursa olsun tarihi, başvurunun yapıldığı tarih olarak değerlendirildiği göz önüne alındığında (ulaştığı veya gönderildiği tarih), dolayısıyla başvuranlar, bu koşullar içerisinde, ihmalkâr davranmış veya bir hata işlemiş olmakla suçlanamazlar.

71. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, idareye başvurunun olayın meydana geldiği tarihten itibaren geçen sürede yapılmadığı ve idarenin kusurlu ihmali bulunduğuyla ilgili bilgi sahibi olmadan yapıldığı gerekçesiyle bu koşullar altında başvurunun geç yapıldığını ileri sürerek reddetmiş ve başvuranları mahkemeye erişim haklarından mahrum bırakmıştır.

72. AİHM, somut olayda Yüksek Mahkeme'nin kabul ettiği yaklaşımla mahkemenin kendi içtihatları arasında bir benzerlik bulunduğuna dair Hükümet'in gerekçelendirmesine katılamamaktadır.

73. Aslında, iç hukukta kararın tebliği öngörülmemiş ise, müracaatların süresi kararın verildiği tarihte değil, tarafların söz konusu kararın içeriği konusunda gerçekten bilgi edindikleri tarihte işlemeye başladığı içtihatlarla sabittir (diğerleri arasında bk. Papachelas / Yunanistan [BD], no. 31423/96, §§ 30-31, AİHM 1999-II ve Seher Karataş / Türkiye, no. 33179/96, §§ 27-29, 9 Temmuz 2002).

74. Sonuç olarak, Sözleşme'nin 6 / 1 hükmü ihlal edilmiştir.

B. Sözleşme'nin 6. Maddesine İlişkin İddia Edilen Diğer İhlaller Hakkında

75. Başvuranlar, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin, başvuranların idareye sundukları dilekçelerini gönderdikleri tarih yerine bu taleplerinin idareye ulaştığı tarihi dikkate alması nedeniyle itiraz etmektedirler. Başvuranlar, bu yaklaşımın makul olmadığını değerlendirmişlerdir.

Başvuranlar, diğer taraftan, sivil olmalarına rağmen başvurularının askeri bir mahkeme yerine sivil idare mahkemesi tarafından incelenmiş olması gerektiğini iddia etmektedirler. Başvuranlar, bu tür bir durumun bağımsız ve tarafsız bir mahkemeye erişme hakkını ihlal ettiği kanaatindedirler. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarına karşı temyiz yolu bulunmaması, adil yargılanma hakkını ihlal edecektir.

76. AİHM' in Sözleşme'nin 6. maddesine ilişkin ortaya koyduğu ihlal tespiti bakımından, başvurunun yapıldığı tarihin belirlenmesine ilişkin şikâyetin ayrı ayrı incelenmesinin gerekli olmadığı kanaatindedir.

77. AİHM, diğer şikâyetlerle ilgili olarak, başvuranlarca dile getirildiği gibi, Sözleşme tarafından güvence altına alınan haklara herhangi bir ihlal teşkil etmedikleri kanaatindedir.

78. Sonuç olarak, bu şikâyetlerin kabul edilemez olduklarına karar vermek gerekmektedir.

II. SÖZLEŞME'NİN 2. MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI HAKKINDA

79. Başvuranlar, yakınlarının yaşam hakkının ihlal edilmesi nedeniyle itiraz etmektedirler. Başvuranlar, Sözleşme'nin 2. maddesini ileri sürmektedirler, bu hükmün somut olayla ilgili kısımları aşağıdaki gibidir:

> "Herkesin yaşam hakkı yasayla korunur."

80. Hükümet, bu iddiaya itiraz etmektedir.

A. Kabul edilebilirlik hakkında

81. Hükümet, Sözleşme'nin 2. maddesine ilişkin şikâyetlerin, iç hukukta henüz tüketilmemiş olmaları nedeniyle kabul edilemez olduklarını değerlendirmektedir çünkü, M.F.E. ile ilgili olarak ceza davası, başvurunun yapıldığı tarihte halen devam etmektedir.

82. Başvuranlar, bu kabul edilebilirlik koşulunun, 15 Nisan 2009 tarihli karar ile tamamlanan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi önündeki yargılama sonucunda, yerine getirildiğini ileri sürmektedirler.

83. AİHM, Hükümet tarafından bahsedilen ceza yargılamasının, gerektiği takdirde, yetkililerin yalnızca katil zanlısına bir silah verilmesinde ihlal söz konusu olmasının değil zanlının mahkûm edilmesine yol açtığını ki bu durumun mevcut başvuruya konu olduğunu tespit etmektedir.

84. Buna karşın, aslında başvuranların açtığı tam yargı davası ve müdahil taraflardan birini oluşturan Üstçavuş C.T. aleyhinde açılan ceza yargılaması da, bu iddia edilen ihmali hedeflemektedir. Bu iki dava

kesinlikle, silahın ihtilaflı bir şekilde M.F.E'ye verilmesine bağlı sorumlulukları ve maruz kalınan zararı belirlemeyi amaçlamıştır ve somut olayda bu unsurlar uygun başvuruları teşkil etmiştir.

85. Başvuranlar, dolayısıyla şikâyetlerinin giderilmesi için kendilerine sağlanan olası ve başarılı makul bakış açıları teşkil eden başvuru yollarını tüketmişlerdir.

86. AİHM, dolayısıyla, Hükümet tarafından tespit edilen kabul edilemezlik itirazını reddetmektedir.

87. AİHM, ayrıca şikâyetin herhangi bir kabul edilemezlik gerekçesiyle örtüşmediğini ve açıkça dayanaktan yoksun olmadığını tespit ederek kabul edilebilir olduğuna karar vermiştir.

B. Esas hakkında

1. Başvuranların yakınının yaşam hakkının korunmasına ilişkin yükümlülüğün yetkililer tarafından yerine getirilmediği iddiası hakkında

88. AİHM, AİHS' nin 2. maddesinden doğan yükümlülük konusunda, söz konusu maddenin birinci cümlesinin Devlet'in kasten ve kanun dışı adam öldürülmesinin engellenmesinin yanı sıra, yargısına tabi kişilerin yaşamının korunması için gerekli tedbirleri almaya Devleti zorladığını hatırlatmaktadır (*L.C.B. / Birleşik Krallık*, 9 Haziran 1998, § 36, *Karar ve Hükümlerin Derlemesi* 1998-III, ve *Osman / Birleşik Krallık*, 28 Ekim 1998, § 115). Bu bağlamda Devlet'in yükümlülüğü, kişiye karşı ihlallerin yapılmasını engelleyici somut ceza yasalarını çıkararak ve ihlallerin öngörülmesi, önlenmesi ve cezalandırılması için oluşturulan uygulama mekanizmasına dayanarak yaşam hakkının korunması temel görevini yerine getirmeyi gerektirmektedir.

89. Kesin bir şekilde tanımlanan bazı koşullarda, ayrıca Sözleşme'nin 2. maddesi, üçüncü bir şahıs tarafından suç teşkil eden davranışlara maruz

kalan kişinin korunması için uygulamaya ilişkin önleyici tedbirlerin alınması amacıyla yetkililere pozitif yükümlülük zorunluluğu getirebilmektedir (*Mastromatteo / İtalya* [BD], no. 37703/97, § 67 *in fine*, CEDH 2002-VIII, *Branko Tomasic ve diğerleri / Hırvatistan*, no. 46598/06, § 50, 15 Ocak 2009, ve *Opuz / Türkiye*, no. 33401/02, § 128, 9 Haziran 2009).

90. Ancak bu durum, Sözleşme'nin bu hükmünden her tür potansiyel şiddeti önleme şeklinde bir pozitif yükümlülük çıkarılabileceği anlamına gelmemektedir. Esasen bu yükümlülük, modern toplumlarda güvenliği sağlamadaki güçlükler, insan davranışlarının önceden kestirilemezliği ve operasyonel tercihlerin önceliklere ve kaynaklara göre yapılmak zorunda oluşu akılda tutularak, yetkililere imkânsız veya orantısız bir külfet yüklemeyecek şekilde yorumlanmalıdır (*Paul ve Audrey Edwards / Birleşik Krallık*, no. 46477/99, § 55, AİHM 2002-III).

91. Dolayısıyla yaşama karşı her risk iddiası, yetkililerin o riskin gerçekleşmesini önlemek için operasyonel tedbirler almalarını gerektirmez. AİHM, bir ya da birden fazla bireyin yaşamına yönelik gerçek ve yakın bir tehlikenin varlığının yetkililer tarafından bilindiği veya bilinmesi gerektiği ve buna rağmen yetkileri dâhilinde, makulce değerlendirildiğinde bu riski bertaraf etmesi beklenebilecek tedbirleri almadıklarının kanıtlanması halinde pozitif yükümlülüğün ihlal edildiğini kabul etmiştir (Bk. *Maiorano ve diğerleri / İtalya*, no. 28634/06, § 106, 15 Aralık 2009, ve bu kararda bulunan atıflar).

92. AİHM, somut olayda, M.F.E' de anksiyete bozukluğu ve antisosyal davranış teşhisi nedeniyle askeri hekimlerce muayene edilmesi sonucunda, sağlık muayenesine tabii tutulduğunu gözlemlemektedir. İlgililer, M.F.E.'ye ilaç tedavisi uygulanması ve takip altına alınmasının gerekli olduğu kanaatine varmışlardır. Hekimler, ayrıca kendisine silah verilmemesi ve nöbet zorunluluğundan muaf tutulmasına ilişkin yetkililere talepte bulunmuşlardır. İlgilinin tedavisi sonucunda,

Yüzbaşı C.İ., hekimlerin önerilerini izleyerek M.F.E.' nin silahını almaya karar vermiştir. Kışla komutasını üstlenecek olan Üstçavuş C.T., bu karardan kişisel olarak bilgilendirilmiştir.

93. Bu tedbirlerin, diğer askerler ve M.F.E.' nin fiziksel bütünlüğü ile yaşamı için her türlü tehlikeyi önlemek amacıyla alındığı açıktır. Burada, bu gibi durumlarda, yetkililerden makul bir şekilde beklenen tedbirler söz konusudur.

94. Yaşam hakkını korumaya yönelik uygun yönetmelik ve idari çerçeve, dolayısıyla asker M.F.E. ile ilgili olarak endişeler görülmesi halinde, uygulamaya konulmuştur.

95. Ancak Yüzbaşı C.İ.' nin bulunmadığına ilişkin komutanlığı inandıran Üstçavuş, hiyerarşik üstlerinin talimatları ile hekimlerin önerilerine rağmen, M.F.E.' ye bir silah verilmesine ve nöbet tutma yükümlülüğünün getirilmesine karar vermiştir.

96. Ayrıca Üstçavuş, önceki gün M.F.E' nin başvuranların yakınına şiddetle saldırmış olmasına rağmen, ilgili kişiyle Selçuk Yabansu' nun yakın noktalarda ve aynı zamanlarda nöbet tutmaları için görev vermiştir.

97. Üstçavuş, böyle davranarak başvuranların yakınını öngörülemez bir tehlikeye atmıştır ancak bu tehlike yinede gerçekleştirilmiştir.

98. Diğer bir ifadeyle, öncelikle Selçuk Yabansu' nun yaşam hakkını korumak için koruyucu düzen tedbirlerinin alınmasına imkân veren yönetmelik ve idari çerçevede, uygulamaya ilişkin bir kusur bulunmaktadır.

99. Bu unsurlar, esas yönden Sözleşme'nin 2. maddesinin ihlal edildiği sonucu çıkarmak için AİHM' e yeterli olmaktadır.

2. Sözleşme'nin 2. Maddesinden Doğan Usuli Yükümlülüklerin İhlal Edildiği İddiası Hakkında

100. AİHM, Sözleşme'nin 2. maddesinin ilk cümlesinde belirtilen pozitif yükümlülüklerin aynı zamanda cinayetin sebebini ortaya koymaya ve

sorumluları cezalandırmaya imkân veren etkin ve bağımsız adli bir sistemin kurulması zorunluluğu getirdiğini hatırlatmaktadır (anılan, *Mastromatteo*, § 89). Benzer soruşturmaların temel amacı, yaşam hakkını koruyan iç hukuk hükümlerinin etkin uygulanmasını sağlamaktır ve görevli ile Devlet yetkililerinin davranışları söz konusu olduğunda, yetkililerin, sorumlulukları altında meydana gelen ölümler hakkında cevap vermesini dikkate almaktadır (anılan, *Paul ve Audrey Edwards*, §§ 69 ve 71).

101. Ayrıca AİHM, soruşturmanın şeklinin koşullara göre değişebilece ğini hatırlatmaktadır. Bir ihmalin olup olmadığını irdelemek söz konusu olduğunda, hukuki yol ya da disiplin yolu yeterli olabilmektedir (*Calvelli ve Ciglio / Italya* [BD], no: 32967/96, § 51, AİHM 2002-I).

102. Somut olayda, AİHM, başvuranların yakınının katil zanlısı aleyhinde ceza yargılamasının açıldığını ve ilk derece mahkemesi önünde zanlının – yirmi beş yıl- ağır hapis cezasına mahkûm edildiğini dikkate almaktadır. Yargılama, Yargıtay önünde halen derdesttir.

103. Bu mahkûmiyet, onaylanması gerekse dahi, Sözleşme'nin 2. maddesine ilişkin usuli yükümlülüklerini yerine getirmek için tek başına yeterli değildir ve bu yükümlülükler Devlet ile görevlilerinin sorumluluğunu ortaya koymaya imkân veren bir başvurunun bulunmasını zorunlu tutmaya kadar gitmektedir (anılan, *Mastromatteo*, §§ 95 ve devamı; anılan, *Mariano ve diğerleri*, §§ 126 ve devamı).

104. AİHM, bu türden bir sorumluluğu ortaya koyabilmek için, başvuranların iki yol izlendiklerini gözlemlemektedir. Bu yollar, idari ve ceza nitelikli müracaat yollarıdır.

105. İdare Mahkemeleri önünde yapılan başvuru ile ilgili olarak, AİHM, Sözleşme'nin 6. maddesi bağlamında, bir mahkemeye erişim hakkına ihlal teşkil ettiği koşullarda şekli kurallara riayet edilmemesi nedeniyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar verildiğini

gözlemlemektedir. Bu bağlamda AİHM, yukarıdaki belirtilen 57. paragrafa ve devamına atıfta bulunmaktadır.

106. Ceza başvurusu ile ilgili olarak, Sözleşme'nin 2. maddesi, üçüncü kişiler aleyhine ceza davası açılmasını isteme hakkını güvence altına almamakla birlikte (*Perez / Fransa [BD],* no: 47287/99, §70, AİHM 2004-I), Mahkeme, gerektirdiği etkili bir yargısal sistem, bazı hallerde ceza hukukuna başvurmayı içerebileceğini ve bazı durumlarda içermesi gerektiğini birçok kez hatırlatmaktadır (anılan, *Maiorano ve diğerleri*, § 128).

107. Bu bağlamda AİHM, görevinde ihmal bulunması nedeniyle Üstçavuş C.T. aleyhine açılan yargılamada, başvuranların mevcut davada müdahil taraf olarak katıldıklarını tespit etmektedir.

108. Bu yargılama, suçun kasıt unsurunun eksik olması gerekçesiyle, C.T.'nin serbest bırakılmasıyla tamamlanmıştır.

109. AİHM, ceza mahkemelerinin "ihmal" iddiasını incelemekle yetindiklerini ve yaşama zarar verme boyutunda davayı ele almanın dışında kaldıklarını dikkate almaktadır.

110. Aslında, söz konusu ceza davası, Sözleşme'nin 2. maddesi bağlamında gerek yaşam hakkının korunmasını gerekse yaşam hakkının ihlalini oluşturan olaylarla hiçbir şekilde ilişkisi bulunmayan, Türk Ceza Kanunu'nun 257/2 hükmü açısından "görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle sanığın olası sorumluluğunu yalnızca ortaya koymayı hedeflemektedir (*Öneryıldız / Türkiye* [BD], no: 48939/99, §§ 115-116, AİHM 2004-XII).

111. Diğer taraftan AİHM, soruşturmanın bazı yönlerinin yetersizliğine ilişkin Başsavcının vardığı sonuçları kabul etmiştir (yukarıdaki 25. paragraf).

112. Yukarıda belirtilenler ışığında, AİHM, olaylara karışan idare bünyesindeki görevlilerin ve/veya söz konusu idarenin olası sorumluluklarının ortaya konulması için Devletin pozitif yükümlülüğünün

yerine getirilmesine imkân verecek hukuki bir cevap olmadığı kanaatindedir.

113. Sonuç olarak, Sözleşme'nin 2. maddesi usul yönünden de ihlal edilmiştir.

III. SÖZLEŞME'NİN 13. MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI HAKKINDA

114. Sonuç olarak, başvuranlar, Sözleşme'nin 13. maddesi bağlamında şikâyetlerini ileri sürmeye imkân verecek bir başvuru yolunun bulunmamasından şikâyet etmektedirler.

115. AİHM, bu şikâyetin, Sözleşme'nin 2. maddesinin usul yönünden ve Sözleşme'nin 6. maddesi açısından incelenmiş olan şikâyetlerden ayrı bir husus ortaya koymadığını değerlendirmektedir.

116. Dolayısıyla, bu şikâyeti gerek esası gerekse kabul edilebilirliği hakkında ayrı olarak incelemeye gerek duyulmamaktadır.

IV. SÖZLEŞME'NİN 41. MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI HAKKINDA

117. Başvuranlar, Hasan ve Muteber Yabansu adına maddi tazminat olarak 100 000 Avro (EUR) talep etmektedirler. Başvuranlar, manevi tazminat olarak 50 000 Avro (EUR) talep etmektedirler. Sonuç olarak, başvuranlar masraf ve harcamalar için 32 500 Avro (EUR) talep etmektedirler.

118. Hükümet, bu talepleri kabul etmemektedir ve AİHM'e bu meblağların reddedilmesini talep etmektedir.

119. AİHM, Sözleşme ihlali ile iddia edilen zarar arasında açıkça bir nedensellik bağının bulunması gerektiğini ve gerektiği takdirde, mali destek

kaybı niteliğindeki bir tazminat içerebileceğini hatırlatmaktadır (*Kavak / Türkiye*, no: 53489/99, § 109, 6 Temmuz 2006).

Oysa somut olayda, AİHM, başvuranların, Selçuk Yabansu'nun bu zamana kadar başvuranlara getirmiş olduğu maddi destekle ilgili olarak, herhangi bir kanıtlayıcı veya açıklayıcı bir belge sunmadıklarını gözlemlemektedir. Dolayısıyla, AİHM maddi tazminat talebini reddetmektedir (*Havva Dudu Albayrak ve diğerleri / Türkiye*, no: 24470/09, § 56, 21 Haziran 2011).

120. Manevi tazminat ile ilgili olarak, AİHM, hakkaniyete uygun olarak, başvuranlara 30 000 Avro (EUR) ödenmesini hükmetmiştir.

121. AİHM, masraf ve harcamalar ile ilgili olarak, Sözleşme'nin 41. maddesi bakımından, masrafların gerçekten sunulduğu ve makul miktarlara tekabül ettiği takdirde iade edilebileceklerini hatırlatmaktadır (*Nikolova / Bulgaristan* [BD], no: 31195/96, § 79, AİHM 1999-II). Ayrıca AİHM, İçtüzüğün 60 / 2 hükmünün Sözleşme'nin 41. maddesi bağlamında sunulan her türlü talebin numaralandırılmasını ve gerekli destekleyici belgelerle birlikte ayrı ayrı başlıklar altında incelenmesini öngördüğünü hatırlatmaktadır, aksi taktide AİHM bu talebi kısmen ya da tamamen reddedebilmektedir. (*Zubani / İtalya* (adil tazmin), no: 14025/88, § 23, 16 Haziran 1999). Oysa AİHM, somut olayda masraf ve harcamaların iadesi talebinin desteklenmesi için uygun herhangi bir belge sunulmadığını – (örneğin, fatura, avukatlık sözleşmesi, avukatlık ücretine ait dekont) gözlemlemektedir. Dolayısıyla, AİHM bu bağlamda meblağların başvuranlara ödenmesinin gerek olmadığı kanaatindedir.

122. Diğer taraftan AİHM, gecikme faizi olarak Avrupa Merkez Bankası'nın marjinal kredi kolaylıklarına uyguladığı faiz oranına üç puan eklemek suretiyle elde edilecek oranın uygun olduğu sonucuna varmaktadır.

BU GEREKÇELERE DAYANARAK, AİHM OYBİRLİĞİYLE,

1. Başvurunun, sürenin başlangıcının hesaplanmasıyla ilgili olduğu gerekçesiyle, yaşam hakkı, etkin başvuru hakkı ve mahkemeye erişim hakkına ilişkin şikâyetleri içeren kısmının kabul edilebilir ve Sözleşme'nin 6. maddesine ilişkin diğer şikâyetlerin kabul edilemez olduğuna;

2. Sözleşme'nin 6/1 hükmünün ihlal edildiğine;

3. Sözleşme'nin 2. maddesinin esas yönünden ihlal edildiğine;

4. Sözleşme'nin 2. maddesinin usul yönünden ihlal edildiğine;

5. Sözleşme'nin 13. maddesine ilişkin şikâyetin kabul edilebilirliğinin ve esasının incelenmesine gerek olmadığına;

6. Sözleşme'nin 44/2 hükmüne uygun olarak, Davalı Devletin başvuranlara, kararın kesinleştiği tarihten başlamak üzere üç ay içerisinde, ödeme tarihinde geçerli olan döviz kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmek üzere manevi tazminat bağlamında 30 000 Avro (EUR) ödemesi gerektiğine;

b) Söz konusu sürenin bittiği tarihten itibaren, ödemenin yapıldığı tarihe kadar, bu miktarlara Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli olan marjinal kredi faiz oranının üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanmasına

7. Başvurunun geri kalan kısmı için yapılan adil tazmin talebinin reddedilmesine

karar vermiştir.

İşbu karar Fransızca dilinde tanzim edilerek İçtüzüğün 77 // 2 ve 3 hükümleri uyarınca, 12 Kasım 2013 tarihinde yazılı olarak tebliğ edilmiştir.

Stanley Naismith	Guido Raimondi
Yazı İşleri Müdürü	Başkan

Annexe

İsim ve Soyad	Doğum Tarihi	Selçuk Yabansu ile Yakınlık Derecesi

Hasan Yabansu	16 Mart 1936	baba
Muhteber Yabansu	5 Mart 1941	anne
Herdem Kartal	16 Şubat 1965	kız kardeş
İhsan Yabansu	12 Mart 1968	erkek kardeş
Şerafettin Yabansu	10 Haziran 1970	erkek kardeş
Yüksel Yabansu	20 Kasım 1976	erkek kardeş
Mayican Türeli	16 Eylül 1981	kız kardeş
İlyas Yabansu	3 Mart 1985	erkek kardeş
Aslihan Temel	8 Haziran 1987	kız kardeş